

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1218/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี  
นาย อำนาจ ก ล้ำ ทรัพย์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 82, มาตรา 277, มาตรา 279

จำเลยชนผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 4 ปีเศษไปดูการ์ตูนที่บ้านจำเลยแล้วพาไปนอนบนกระดาน ถอดกางเกงผู้เสียหายและจำเลยออก แล้วจำเลยใช้อวัยวะเพศดันไปตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหายเพียงครั้งเดียว บริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายไม่มีบาดแผล จำเลยไม่ได้กระทำซ้ำต่อไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ทั้ง ๆ ที่จำเลยมีโอกาที่จะกระทำได้นับได้ว่าเป็นการยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80,82

แม้ผู้เสียหายไม่มีช่องคลอด ผิดปกติแต่กำเนิด อันเป็นเหตุประกอบให้เห็นว่าโดยสภาพวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อทำให้การกระทำของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ก็ตาม ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยหยุดการกระทำต่อผู้เสียหายเพราะได้เห็นหรือทราบข้อเท็จจริงอันนี้ เมื่อจำเลยยับยั้งเสียเองได้ จำเลยก็ไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้นคงมีความผิดเท่าที่ต้องตามกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด คือกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงนิติมาเคยนาอายุ 4 ปี เศษ โดยจำเลยได้กระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผลเพราะขนาดของ อวัยวะเพศของจำเลยและของผู้เสียหายแตกต่างกันมาก และจำเลยได้ดมแก้้มผู้เสียหาย อันเป็นการกระทำอนาจารผู้เสียหายด้วย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 277, 80, 279, 91 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 81, 277 วรรคแรก, 279 ที่แก้ไขแล้ว ลงโทษตามมาตรา 81, 277วรรคแรก อันเป็นบทหนักให้จำคุก 3 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องรับโทษฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82 คงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ให้จำคุก 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยชวนผู้เสียหายไปดูหนังสือการ์ตูนที่บ้านจำเลย แล้วพาผู้เสียหายนอนบนกระดาน ถอดกางเกงผู้เสียหายและจำเลยออกแล้วจำเลย เอาอวัยวะเพศดันไปตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวผู้เสียหายไม่ร้อง จำเลยไม่ได้กอดจูบไม่ได้หอมแก้้ม ต่อจากนั้นจำเลยก็อุ้มผู้เสียหายไปส่งนางสาว ปราณีน้าของผู้เสียหาย แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศดันไปตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหายเพียงครั้งเดียว และไม่ได้กระทำซ้ำต่อไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ทั้ง ๆ ที่ จำเลยมีโอกาที่จะกระทำได้เพราะบริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยวและผู้เสียหายก็มีได้

ร้องซึ่งนับได้ว่าเป็นการยับยั้งเสียเอง ไม่กระทำการให้ตลอด จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80, 82 ฯลฯ แม้ตามรายงานแพทย์ระบุว่า ผู้เสียหายไม่มีช่องคลอดผิดปกติแต่กำเนิดอันเป็นเหตุประกอบให้เห็นว่า โดยสภาพวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อทำให้การกระทำของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ นั้น ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยหยุดการกระทำต่อผู้เสียหายเพราะได้เห็นหรือทราบข้อเท็จจริงอันนี้ ดังนั้นเมื่อจำเลยยับยั้งเสียเองได้ จำเลยก็ไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำผิดนั้นคงมีความผิดเท่าที่ต้องตามกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด คือกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ